

1541146-59.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITOS AFASTADOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, "as condenações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1541146-59.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1541146-59.2021.8.26.0050, c. 12/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2341246/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 16116149 - 14º D.P. PINHEIROS, 7158/21/314 - 14º
D.P. PINHEIROS, 2341246 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPPE DE NORONHA XAVIER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

FELIPPE DE NORONHA XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta de 06h50min, na Rua Bacopari nº 57, Alto de Pinheiros, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo Moto E, pertencente à vítima Sandra Maria Santos Ribeiro. A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 85/91). O réu foi citado (fls.119) e apresentou defesa preliminar (fls. 135). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado. Não foram requeridas diligências

pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, mas com o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, agravante da reincidência dupla, sem compensação com a confissão e regime fechado como inicial para cumprimento de pena.

A defesa pugnou pela absolvição pela inimputabilidade. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a incidência da atenuante da confissão e e fixação de regime menos gravoso.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente em parte.

A vítima S. narrou que no dia dos fatos caminhava em direção ao seu trabalho, por volta das 7 horas, quando um moto com o condutor passou de devagar e parou perto de si, sendo que o condutor desembarcou e abordou a declarante, com a mão na cintura, ordenando que entregasse seu celular. A depoente chegou a pedir para que ele não subtraísse o aparelho, mas o indivíduo perguntou se ela queria “tomar um tiro”, motivo pelo qual entregou seu aparelho ao indivíduo, que deixou o local em seguida. Não chegou a ver qualquer arma de fogo. Pediu socorro para seguranças da rua. No dia seguinte foi procurada por tais seguranças que lhe entregaram imagens do momento do crime. Foi ao Distrito Policial para efetuar o registro da ocorrência e entregou tais imagens. Em tal ocasião não efetuou qualquer reconhecimento. Após cerca de dois dias foi chamada para realizar reconhecimento pessoal, oportunidade em que lhe foi exibido apenas um indivíduo, o qual a depoente reconheceu sem hesitações. Não recuperou seu aparelho. Na presente data reconheceu o réu sem hesitações.

O policial civil Douglas narrou que após o registro da ocorrência pela vítima e fornecimento de imagens do crime efetuou diligências no local dos fatos, obtendo mais imagens de câmeras, as quais permitiram que a placa da moto usada no crime fosse identificada. Efetuada pesquisa, constataram que a placa estava registrada em nome de uma mulher. Diligenciaram no endereço de registro, onde foram atendidos por um homem, que informou que era marido da proprietária, que não se encontrava no momento. Mas, ele esclareceu que a moto estava em poder do filho dela, o qual ele havia expulsado de casa após uma discussão. Tal homem indicou onde o rapaz poderia ser encontrado, um local onde costumava fazer uso de drogas. Rumaram para o local indicado e ali encontraram a moto e o réu. Em conversa, ele confessou a prática delitiva, não especificando se havia utilizado arma de fogo. Ele disse que já havia trocado o celular por drogas. A autoridade policial representou pela prisão temporária do réu e o depoente não mais acompanhou as investigações, não sabendo informar se a vítima foi chamada para efetuar reconhecimento.

O policial Christian afirmou apenas ter participado da confecção do relatório.

O réu em seu interrogatório confessou a prática delitiva. Disse que estava realizando tratamento no CAPS, mas que foi expulso de casa por seu padrasto após uma discussão, motivo pelo qual teve uma recaída e voltou a usar drogas sem controle. Negou o emprego de arma de fogo.

Não há que se falar em inimputabilidade. Com efeito, nada há nos autos que indique que o réu seja portador de alguma doença que o torne incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar segundo tal entendimento. Apenas há a narrativa dele de que fazia tratamento para tratar sua dependência química, com internações. Mas, o réu demonstrou raciocínio lógico e coerente, sem qualquer comprometimento aparente, que justifique a instauração de incidente para aferição de sua capacidade ao tempo dos fatos. O uso pré-ordenado e voluntário de substâncias tóxicas não afastam a ilicitude de sua conduta, tampouco a sua culpabilidade.

Há prova suficiente quanto à autoria delitiva em seu desfavor, que foi reconhecido, com segurança, pela vítima, nesta oportunidade. Ressalte-se que a vítima afirmou que a despeito de o réu estar usando capacete no momento da prática delitiva era possível visualizar seu rosto pois a viseira estava aberta. Mostrou-se segura no reconhecimento, que afirmou ter feito com segurança também na fase policial. Sendo certo que a vítima prestou depoimento firme e coeso, esclarecendo de maneira

lógica o desenvolvimento dos fatos, inclusive, relatando as condutas do réu durante o roubo, em consonância com o relatório das investigações (fls. 05/12), o que ratifica a higidez de seu depoimento e do reconhecimento efetuado, sendo certo que o réu não trouxe ao conhecimento do Juízo qualquer circunstância que possa viciar o depoimento por ela prestado.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delitosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssono e harmônico com o depoimento da vítima, esclarecendo sobre o desenrolar dos fatos que culminaram com a identificação do réu. Neste sentido, narraram a análise das imagens apresentadas pela vítima, a identificação da placa do motociclo e a relação do nome da genitora do réu em um boletim de ocorrência, fato que os levou à pessoa do réu, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras.

Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Há ainda a própria confissão do réu, repetida em Juízo.

Com efeito, o emprego de arma de fogo não restou devidamente demonstrado, já que a vítima relatou não ter visto qualquer arma em poder do réu, esclarecendo apenas que ele fazia menção de portar uma, mas o armamento não foi exibido, o que impede o reconhecimento da majorante em questão.

Com efeito, houve a consumação do delito, na medida em que os agentes obtiveram a posse do numerário subtraído dos caixas do estabelecimento comercial vítima. O E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse do celular, sendo que o objeto sequer foi recuperado.

Assim, o réu deve ser condenado pela prática do crime nos termos acima expostos.

Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal à espécie, sendo que as circunstâncias e consequências do crime não vão além daquelas ordinariamente previstas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato, motivo pelo qual sua pena será fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente (6ª Vara Criminal, autos 1512019-27.2021 – fls. 121/122) e confessou integralmente a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, motivo pelo qual, nesta segunda fase da dosimetria, a pena remanescerá inalterada. Anoto que o entendimento pessoal desta magistrada é no sentido de que condenação por porte de drogas para uso próprio tem o condão de gerar reincidência, pois não houve abolitio criminis, mas mera ausência de estipulação de pena privativa de

liberdade, o que não exclui o caráter ilícito da conduta. No entanto, após diversas reformas das sentenças proferidas e observando-se o entendimento mais recente do E. STJ, no sentido de que tal tipo de condenação não gera reincidência ou mau antecedente, curvo-me a tal entendimento. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITOS AFASTADOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, "as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade" (HC n. 453.437/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, não obstante os esforços do Parquet, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto aplicado o entendimento acima referido, afastando-se os efeitos da reincidência do paciente, não há, portanto, que se falar em reforma ou reconsideração da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 505536 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/09/2019)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar a questão, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não é apta a gerar os efeitos da reincidência. 3. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie. 5. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejuízo da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado." (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1774124 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 02/04/2019)

Assim, a condenação dos autos da 12ª Vara Criminal (fls. 121) não será considerada como reincidência. A condenação perante a 31ª Vara Criminal ainda não transitou em julgado, conforme certidão de fls. 175/176.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição As condições do réu são modestas, de forma que fixo cada dia-multa no mínimo legal. Tendo em conta a reincidência específica do réu, bem como o fato de que estava em liberdade havia poucos meses (foi solto em 20/07/2021), indicando total indiferença à terapêutica penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo

como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal, o réu FELIPPE DE NORONHA XAVIER, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 141.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Em que pesem as lesões apontadas no laudo IML do réu (fls. 104/105), deixo de determinar apuração por parte da Corregedoria da Polícia Civil eis que ausentes alegações do réu quanto a eventuais agressões por parte dos policiais, e, ainda, tendo em vista que as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa dos fatos apurados no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA